

1500262-66.2021.8.26.0218

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE CALDAS NERY SOARES

Comarca: Guararapes

Foro: Foro de Guararapes

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... Paulo em situações análogas:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONFIGURADA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RÉUS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararapes

Foro de Guararapes

2ª Vara

Rua Luiz Lincoln de Oliveira s/n, Guararapes-SP - cep 16700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500262-66.2021.8.26.0218 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500262-66.2021.8.26.0218

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2111940/2021 - DEL.POL.GUARARAPES, 12240309 - DEL.POL.GUARARAPES, 423/21/215 - DEL.POL.GUARARAPES, 2111940 - DEL.POL.GUARARAPES, 423/2021 - Delegacia de Polícia de Guararapes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE CALDAS NERY SOARES

Vistos.

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, conhecido por "Neguito", qualificado à fl. 113, CÉSAR DA SILVA DE SOUZA, conhecido por "Garoto", qualificado à fl. 03, e FELIPE DANIEL GOMES, qualificado à fl. 35, foram denunciados como incursos nos artigos 33, caput, e 35, ambos combinados com o artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, sob os consectários da Lei nº 8.072/90, porque, supostamente, em data não precisamente apurada, porém até o dia 25 de fevereiro de 2021, em locais e horários incertos, nesta cidade e Comarca de Guararapes/SP, com vontade consciente, agindo em conluio e com unidade desígnios, prestando-se assistência mútua e material relevante, associaram-se entre si e com Gean Vitor Alvares Caldas e Luís Henrique Alvares Caldas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Ausentes as causas de rejeição do artigo 395 do CPP, a denúncia foi recebida em 28/03/2022 (fls. 450/451) e os réus foram citados para responder à acusação (artigo

396 do CPP) apresentadas às fls. 389/395; 418/420; e 434/441 (artigo 396-A do CPP). Não sendo o caso de absolvição sumária (artigo 397 do CPP), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 450/451).

Na fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa. Ao final, os réus foram interrogados.

Ausentes requerimentos de diligências complementares (artigo 403 do CPP), as partes ofereceram alegações finais escritas (fls. 581/589, 593/598, 601/607 e 608/653).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO (artigo 93, inciso IX, da CRFB/88).

Passo à análise das preliminares aventadas.

A preliminar de inépcia da denúncia suscitada em memoriais finais de Felipe Daniel (fls. 608/653) não merece acolhida. Isso porque, a peça inicial acusatória contém clara exposição dos fatos e explícita de forma detalhada porque cada um dos réus teria participado do crime, preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP. A existência ou não de prova a permitir a condenação de cada um dos réus é matéria de mérito e como tal será analisada no momento oportuno.

Igualmente, não merece acolhida a alegação de existência de ilegalidade da extração de prints nos aparelhos celulares apreendidos no bojo da investigação. Ora, havendo decisão judicial autorizando o acesso ao conteúdo do aparelho celular apreendido, inclusive mensagens oriundas de sms ou de qualquer outro aplicativo nele instalado, a fim de possibilitar outros elementos informativos da prática do crime, por consequência, autorizada está a documentação de referidos elementos informativos angariados.

Não havendo nulidade a sanar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Apesar de constar na denúncia a capitulação dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e, em que pese o órgão acusatório ter postulado inicialmente a condenação dos réus pela prática de ambos os crimes, de rigor o decreto condenatório nos termos capitulados na alegação final de acusação, que pretende ver procedente a referida ação penal tão somente no que tange ao artigo 35 do supramencionado diploma legal (associação ao tráfico de drogas).

Isso porque, apesar de haver indícios de que os acusados tenham realizado a mercancia ilícita, tenho que os elementos de provas colhidos durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são insuficientes para apontá-los, no presente caso, como coautores do delito capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porquanto o conjunto probatório ressurte-se de robustez, mostrando-se insuficiente à comprovação da prática do tráfico de drogas por parte dos réus.

Estando os autos eivados de dúvidas, desautorizada está a procedência da acusação.

Afinal, para a sua procedência, exige-se do Magistrado uma atividade de cognição vertical exauriente (juízo de certeza), que resta impossibilitada pelas patentes situações duvidosas encontradas no presente feito. Com efeito:

“Dúvida que perturbe o espírito do Magistrado será a que basta a endireitar-lhe os passos para o caminho da absolvição, em obséquio ao princípio de nomeada universal: In dubio pro reo. Dúvida, em Direito Penal, equivale a ausência de prova” (Voto Nº 4.246).

Daí porque, “uma condenação criminal deve apoiar-se em prova extrema de dúvidas. Presunções e meros indícios não ostentam qualidades de segurança e certeza, por não servirem de fundamento a decreto condenatório.” (Apelação nº 660.325/7, Julgado em 22/08/1991, 1ª Câmara, Relator: Pires Neto, RJDTACRIM 11/118).

Ressalte-se, por oportuno, que o ônus de provar a materialidade e a autoria do crime compete à acusação, não se podendo presumir a culpabilidade do réu, mas sim a sua inocência, como decorrência lógica do princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“princípio da presunção de inocência: também conhecido como princípio do estado de inocência ou da não culpabilidade, significa que todo acusado é presumido inocente,

até que seja declarado culpado por sentença condenatória, com trânsito em julgado. Encontra-se previsto no art. 5.º, LVII, da Constituição. O princípio tem por objetivo garantir que o ônus da prova cabe à acusação e não à defesa. As pessoas nascem inocentes, sendo esse o seu estado natural, razão pela qual, para quebrar tal regra, torna-se indispensável que o Estado-acusação evidencie, com provas suficientes, ao Estado-juiz a culpa do réu" (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13ª ed., Rio de Janeiro, Forense: 2014).

Posto isso, a ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) praticado pelos acusados, tem-se que o quadro probatório produzido nos autos permite a segura conclusão quanto à associação destes para a prática delitiva, já que havia uma estrutura coesa e estável para a prática do crime.

No âmbito da materialidade, a prova é constituída pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04; 26/28; 38/39; 61/62; 65/66; 186/187; e 216/217); auto de exibição e apreensão (fls. 40; 63; e 67); laudos periciais (fls. 29/31 e 32/34); relatórios de investigação (fls. 05/10, 86/96 e 123/125); e, em conformidade com o disposto no artigo 167 do Código de Processo Penal, pela prova oral colhida.

A testemunha Jair Santos Rocha, policial civil, responsável pelos relatórios dos celulares, ouvida apenas em juízo (mídias audiovisuais) afirmou que, na análise do celular de Luís Henrique, havia conversas sobre entorpecente. CÉSAR, conhecido por "Garoto", e Luís Henrique conversaram sobre a compra de drogas, sendo o primeiro o vendedor. O celular de CÉSAR foi apreendido posteriormente, na segunda operação ocorrida. FELIPE DANIEL também conversou com Luís Henrique, mencionou "bagulho", expressão utilizada para se referir à droga ou petrecho. Luís Henrique se referiu a "Neguito", alegando que este teria o tal "bagulho". O celular de FELIPE DANIEL também foi periciado e reforçou o seu envolvimento com o tráfico de drogas. CARLOS EDUARDO também teve seu celular apreendido e periciado, sendo constatada diversas conversas sobre o tráfico de drogas. Pela sua experiência, os diálogos demonstram o vínculo para a traficância entre os acusados. Esclareceu que FELIPE DANIEL, ao tempo da prisão, estava desempregado, mas, anteriormente, tinha trabalho como entregador em uma farmácia.

A testemunha Ronaldo Marcos Jacob, delegado de polícia que presidiu o inquérito policial, ouvida apenas em juízo (mídias audiovisuais) relatou que, em 25 fevereiro de 2021, foi deflagrada a operação "FOX 1". A Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, deu cumprimentos a diversos mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos nos autos 1500119-77.2021.8.26.0218, da 2ª Vara desta Comarca, visando combater o tráfico de drogas nesta cidade. Na ocasião, Gean Vitor Alvares Caldas e Luís Henrique Alvares Caldas, que são irmãos, foram presos em flagrante delito por tráfico de drogas e denunciados como incurso no artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 (autos de nº 1500318-11.2021.8.26.0603, da 2ª Vara Criminal desta Comarca). Após autorização judicial, o setor de investigação da Delegacia de Polícia Guararapes passou à análise do aparelho celular de Luís Henrique, descobrindo o envolvimento dos irmãos com os denunciados CESAR, CARLOS EDUARDO e FELIPE DANIEL, com o tráfico de drogas, estando todos associados para essa prática delitiva. Nos relatórios dos celulares apreendidos, há conversas sobre o tráfico de drogas entre os investigados, demonstrando claramente o envolvimento deles no crime. Posteriormente, foi deflagrada a "Operação Babel", em que CÉSAR foi preso por tráfico de drogas. Apurou-se que CÉSAR utilizava o celular de Yara, sua esposa. No celular de FELIPE DANIEL há conversa sobre "bagulho". Na conversa entre FELIPE DANIEL e CÉSAR sobre entrega, indica que seria de entorpecentes. Verificou-se que Luís Henrique fazia a ponte entre FELIPE DANIEL e CARLOS EDUARDO.

A testemunha Caio Augusto dos Santos, ouvida apenas em juízo (mídias audiovisuais), disse conhecer FELIPE DANIEL e CARLOS EDUARDO. Ele confirmou ter conhecimento de que CARLOS EDUARDO repassou uma Parati para FELIPE DANIEL, como forma de ressarcimento do dano causado ao veículo deste. FELIPE DANIEL iria "assumir" as parcelas vincendas. Sabe que FELIPE DANIEL já trabalhou na farmácia como entregador. Não sabe dizer se este é usuário de drogas.

Já a testemunha Luiz Gustavo de Freitas Contini, ouvida também apenas em juízo (mídias audiovisuais), afirmou conhecer o réu FELIPE DANIEL há, aproximadamente,

três ou quatro anos. Relatou que FELIPE trabalhou na farmácia como entregador. Disse que alguns funcionários vendem Viagra para clientes que têm vergonha de irem ao local. Soube do incêndio do veículo e que CARLOS EDUARDO entregou veículo para FELIPE DANIEL.

Registre-se, por oportuno, que em observância à determinação constitucional da razoável duração do processo, bem como do disposto na Resolução nº 105/2010 do CNJ, desnecessária a transcrição dos depoimentos. No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 5. O art. 405 do Código de Processo Penal possibilita o registro dos termos da audiência de instrução em meio audiovisual. Tal regra - cuja redação foi conferida pela Lei n.º 11.719/2008 - não tem o escopo somente de reduzir o tempo de realização do ato, em razão da desnecessidade da redução, a termo, dos depoimentos do acusado, vítima e testemunhas, mas, também o de possibilitar registro fiel da íntegra do ato, com imagem e som, em vez da simples escrita. Vê-se, assim, que o dispositivo não causa prejuízo às partes. Ao contrário, fortalece a sua segurança. 6. Por isso, corretamente, estabelece o art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal, que, "no caso de registro audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição". 7. A busca da celeridade na prestação jurisdicional é hoje imperativo constitucional, estabelecido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, segundo o qual "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." O fato de não terem sido gravados e transcritos depoimentos orais alinhou-se ao espírito da referida norma constitucional. 8. No mais, se ao Julgador ocorre a necessidade de ter acesso ao conteúdo dos depoimentos gravados em meio audiovisual, pode fazê-lo com o auxílio de uma miríade de equipamentos, dispensada efetivamente a gravação. 9. O Poder Judiciário brasileiro, a bem de todos, tem buscado nos recursos tecnológicos meios para otimizar a prestação jurisdicional, devendo se harmonizar com este horizonte todos aqueles que nele atuam. (...)" HC 177195 / SP. Também: (...) 1. A mens legis do artigo 405 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 11.719/08, consiste em impor como regra o registro dos depoimentos por meios ou recursos de gravação, dentre os quais se declina o audiovisual, afastando-se a necessidade de sua transcrição. RHC 47283 / RS.

Pois bem.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, anotando-se que as palavras dos policiais civis se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando os acusados, então, o ônus de contrastá-las, o que não fizeram.

Com efeito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.

Nesse sentido:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam". (Des. Antônio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap. Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,

SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016).

O acusado Carlos Eduardo de Oliveira deixou de ser ouvido em fase policial. Interrogado em juízo (mídias audiovisuais), declarou ser usuário de cocaína e, à época, estava "encostado". Negou a prática dos crimes narrados na denúncia. Esclareceu que conhece FELIPE, que lhe emprestou o carro, mas ele pegou fogo. Por isso, repassou seu veículo para FELIPE, com a condição deste continuar o pagamento das parcelas, mas assim não ocorreu. "Renato Marreta", o vendedor do carro, o cobrava as parcelas, motivo pelo qual mandou mensagens para FELIPE nesse sentido. Desconhecia qualquer envolvimento dos corréus com droga. Conheceu Luiz Henrique na "biqueira", pois consumia droga e já mandou mensagem para ele, perguntando sobre a disponibilidade de droga para ele comprar. Desconhecia Gean. Também não conversou com os corréus sobre drogas.

Por sua vez, o acusado Cesar da Silva de Souza, ouvido em sede policial (fl. 314), reservou-se ao direito de permanecer calado. Em juízo (mídias audiovisuais), narrou que, à época da prisão, estava desempregado. Foi usuário de cocaína até dois meses antes da prisão. Sobre os fatos narrados na denúncia, nada ter a declarar.

Esclareceu que tinha um celular registrado em nome de Yara, sua esposa, contudo ele tinha desaparecido em dezembro de 2020. Também não conseguiu cancelar a conta.

Conhece FELIPE, pois este trabalhava em uma farmácia. Já mandou mensagem ou ligação para FELIPE, perguntando sobre medicamentos, contudo, nunca mandou mensagem para ele sobre outros assuntos. Para realizar essas conversas, valia do seu celular, que estava cadastrado em nome de Yara. Conhece Luis Henrique e Gean Vitor, pois eles moravam próximo de sua residência e soube que eles foram presos, mas não sabia dizer se eles eram usuário de drogas ou traficantes.

Por fim, o acusado Felipe Daniel Gomes, ouvido em sede policial (fl. 35), reservou-se ao direito de permanecer calado. Interrogado em juízo (mídias audiovisuais), relatou que não faz uso de drogas e, aos finais de semana, faz uso de bebida alcoólica. Alegou que o setor de investigação da Polícia Civil retirou apenas trechos de conversas que interessavam à Polícia, contudo negou qualquer envolvimento com o crime. Esclareceu que conversou com o corréu CÉSAR sobre a entrega de remédios e fraldas, assim como com outros consumidores. Morava no mesmo bairro que CÉSAR. Também conhecia CARLOS EDUARDO. Conhece, a pouco tempo, Agnaldo, alegando ter feito empréstimo com ele para auxiliar em despesas domésticas. Como não conseguiu pagar, era cobrado por Agnaldo. Tinha um carro e o emprestou para CARLOS EDUARDO, tendo havido explosão. Por isso, CARLOS EDUARDO lhe entregou, ficando combinado de pagar o restante das parcelas, mas o veículo apresentou defeitos e, em razão disso, deixou de honrar o compromisso. CARLOS EDUARDO passou, então, cobrá-lo por essa dívida. Disse que não tinha conhecimento sobre a vida pessoal dos corréus, não sabendo dizer se eles usavam droga. Conhecia Gean e Luiz Henrique, mas desconhecia o envolvimento deles com o tráfico de drogas. Nunca morou em Araçatuba, desconhece qualquer policial civil de Araçatuba. Não tem "nada contra" algum policial civil desta comarca. A expressão "bagulho", utilizada nas conversas, não se referia à droga, mas a leite ou fralda, pois essa gíria era comumente utilizada e, à época, trabalhava na função de entregador em uma das farmácias da cidade. Indagado sobre os áudios em que ele foi mencionado na denúncia, esclareceu tratar-se de assunto da farmácia, sendo certo que, em um deles, o cliente solicitou Viagra, mas, por receio, não mencionou o nome do fármaco.

Como percebo, em que pese a negativa dos réus quanto ao cometimento do crime, as versões apresentadas encontram-se amplamente dissociada das demais provas coligidas aos autos, em especial dos relatórios de investigação de fls. 05/10, 86/96 e 123/125 e das declarações colhidas em juízo.

Ora, tem-se que o quadro probatório produzido nos autos permite a segura conclusão quanto à associação destes para a prática delitiva, já que havia uma estrutura coesa e estável para a prática do crime.

Depreende-se das conversas extraídas dos celulares apreendidos (fls. 86/96), que há uma organização entre os envolvidos para a consecução do delito. Há conversas entre Carlos Eduardo, conhecido por "Neguito", e Cesar, que indica uma negociação da substância ilícita (fl. 88).

Verificam-se ainda áudios entre Felipe Daniel e Luís Henrique (fls. 05/10 e 86/96), onde Felipe conversa com Luís acerca de um possível empréstimo de entorpecentes, pois estaria em dívida com um fornecedor e pretendia pagar com empréstimo de drogas do fornecedor Carlos Eduardo, vulgo "Neguito". Vejamos:

Print 11 – áudio 15s (Luís Henrique): ô cusão, dei um salve nele, ele falou que o bagueio tá com o Neguinho mano, aí eu mandei mensagem pro Neguinho, ele falou que deixou o neguinho ciente que eu ia precisa de um pouco, aí eu dei um salve nele pra pegar, aí eu já te respondo aí já quando ele me responder aqui.

Print 11 – áudio 15s (Luís Henrique): ô cusão, deixa eu fala pra você viado, eu consegui arrumar aqui com o Dri mano, aí como que é, você vai cola aqui pra buscar ou você quer que leva aí mano? Aí se vê a mensagem aí você dá um salve aqui. (fl. 08)

E continua:

- Áudio 1: (desconhecido/não identificado) - Tem sim cachorro, o Aguinaldo estava querendo falar com você mano. Não sei se ele foi na sua casa, estava querendo falar com você. Ele não tinha seu número novo. Mas vou te passar aí.

- Áudio 2: (voz de Aguinaldo Soares dos Santos, vulgo Guina) - E aí fi, ou é o Aguinaldo aqui mano, não fico atrás de você não parça. Toda vez eu fico atrás de você, não devo nada pra você não mano, você que me deve mano. Mandando mensagem, te ligando na caminhada, nem satisfação você dá mano? Faz favor mano, eu quero meu dinheiro até sexta-feira hein mano? Se não chegar meu dinheiro até sexta-feira, sem maldade mano, não vou responsabiliza pela minha atitude também não mano. Fica tirando o bagueio aí, vou tirar também mano, de outra forma hein.

- Áudio 3: (voz de Felipe Daniel Gomes) - O parça, se tiver suave de entrega cola aqui na minha vó. Se tiver meio moiado, deixa dentro da caixinha do correio lá em casa, que a hora que eu chegar eu pego, falô? Já vou agilizar as caminhada já pra você já.

- Áudio 4: (desconhecido/não identificado) - E aí Lipe, firmeza? Onde você tá nego véi?

- Áudio 5: (desconhecido/não identificado) - Ô Lipe, separa duas aí pra mim aí, dessa boa que você tá falando aí, demoro? Posi.

- Áudio 6: (voz de Aguinaldo Soares dos Santos, vulgo Guina) - Cachorro, é o seguinte mano, vê quanto você tem na mão aí já que eu vô passar aí pra pegar, porque é o seguinte, tem que mandar a moeda pro mano lá entendeu? (fl. 93)

Ainda, observou-se na perícia realizada no celular de Carlos (fls. 221/229) a existência de mensagens enviadas por Carlos Eduardo, vulgo "Neguito", cobrando valores de Felipe Daniel, corroborando as conversas em que Felipe conversava com Luís acerca do empréstimo de entorpecentes ou apetrechos, a ser feito por Carlos Eduardo.

A conduta descrita no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 vem representada pelo verbo "associar", que significa agregar-se, unir-se.

Essa associação, no entanto, deve observar um mínimo de estabilidade. Não se confunde, assim, com o mero concurso de agentes.

O crime de associação somente se caracteriza quando ocorre estabilidade e permanência entre os agentes, circunstância que restou devidamente demonstrada pela prova oral colhida.

Tal qual o crime de associação criminosa, a associação para a traficância exige elo perene e estruturado entre agentes para a prática do crime. O de associação em especial para o crime de tráfico. É delito autônomo e dispensa até a prova do tráfico, suficiente a finalidade da associação. Porém, inadmissível que toda e qualquer comparsaria para a prática delituosa, quando provada, aponte objetivamente a responsabilidade por tal delito autônomo, sendo imprescindível a prova da perene associação entre os sujeitos, com a finalidade específica da traficância.

A conclusão encontra-se respaldada pelo entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em situações análogas:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONFIGURADA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RÉUS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO.

IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. 1. As materialidades e as autorias dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas na posse dos réus. Circunstâncias do caso concreto indicam a narcotraficância. A respeito do crime de associação para o tráfico (art. 35, "caput", da Lei n. 11.343/06), este restou configurado, posto que presentes os elementos caracterizadores da infração penal, quais sejam, o número de agentes (seis pessoas), a estabilidade ou permanência, e o liame subjetivo entre os réus para a prática do crime. Isso demonstra serem eles integrantes de uma estrutura muito bem organizada de narcotraficantes que visa ao estabelecimento de uma "clientela" no local, por meio da distribuição dos entorpecentes. 2. Depoimentos dos policiais harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. 3. Dosimetria das penas estabelecida de modo escorreito. 4. Não há que se falar no reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, porque os réus se dedicam a atividades criminosas, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, 03 tijolos de "cocaína" (pesando 3.150 gramas), 07 sacolas plásticas contendo "cocaína" (pesando 11.650 gramas), 01 sacola plástica contendo "maconha" (pesando 2.750 gramas), 03 sacolas plásticas contendo "maconha" (pesando 2.350 gramas), 03 pacotes contendo "cocaína" (pesando 428 gramas), 05 pacotes plásticos contendo "crack" (pesando 1.446 gramas) e 01 tijolo de "maconha" (pesando 780 gramas), além de duas peneiras, cinco balanças de precisão, sete bacias de plástico, diversos sacos plásticos para embalagem, um liquidificador, uma marreta, diversas embalagens de "eppendorfs", objetos estes característicos da prática do narcotráfico, bem como três cadernos contendo anotações referentes à venda de drogas, estão a evidenciar que não estavam, por mero acaso, a praticar o crime de narcotráfico. Isto porque, a própria quantidade de substâncias entorpecentes que eles guardavam e tinham em depósito, não há negar-se, vincula-os a um esquema maior de prática criminosa narcotraficante, a evidenciar que eles se dedicam às atividades criminosas, tanto assim que também condenados pela prática de crime de associação para o tráfico. Afinal, quem a elas não se dedica não conseguiria, sem mais nem menos, estar em poder dessa acentuada quantia de substâncias entorpecentes, voltadas à venda, vindo os réus a ser o elo final de toda uma cadeia criminosa, os encarregados, justamente, da disseminação, propriamente dita, das substâncias entorpecentes, que de mais a mais não consta fossem por eles produzidas, de modo que, necessariamente, como acima adiantado, estão eles inseridos na ponta final de uma corrente criminosa, sem se olvidar tratar-se o réu Orlando Pereira de reincidente na prática de crimes. Precedentes do STF. 5. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de narcotráfico será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto. 6. Do mesmo modo, o regime inicial para o cumprimento da pena pelo crime de associação para o tráfico será o fechado, porém, autonomamente em relação ao tráfico de drogas, dadas as circunstâncias do caso concreto (natureza e a quantidade das drogas apreendidas. 7. Improvimento do recurso defensivo. "(TJ-SP - APL: 01032692220118260050 SP 0103269-22.2011.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 21/05/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 18/06/2015) - destaquei. Como se vê, a associação, crime autônomo em relação aos fins visados, como sociedades sceleris, foi suficientemente demonstrada, afastando-se o mero concurso de agentes. Assim, o conjunto probatório deixa evidente a estabilidade e a permanência na associação entre os acusados, para o fim de praticarem o tráfico de drogas. De rigor, portanto, a procedência da ação penal porquanto a prova produzida é francamente hostil aos acusados, sendo inviável a absolvição. Estabelecidas essas premissas quanto à análise da materialidade, autoria e tipicidade, passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e

repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira etapa, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, cumpre reconhecer que os acusados Felipe Daniel Gomes e Cesar possuem BONS ANTECEDENTES, agiram com CULPABILIDADE normal à espécie; não há elementos nos autos para aferir a PERSONALIDADE ou CONDUTA SOCIAL destes; os MOTIVOS, as CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS são inerentes ao delito; não há que se apreciar acerca do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. Não por outra razão, fixo a pena-base, para cada um dos réus, em seu patamar mínimo abstratamente previsto, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Ainda na primeira fase, forçoso reconhecer que o réu Carlos Eduardo (proc. 2266-68.2012 - fl. 379; e proc. 4625-59.2010 - fls. 380/381) ostenta MAUS ANTECEDENTES. Por essa razão, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que não há circunstâncias atenuantes ou agravantes para os réus Felipe Daniel e Cesar, de forma que mantenho a reprimenda fixada na etapa anterior.

No tocante ao réu Carlos Eduardo, forçoso reconhecer a agravante genérica da reincidência (proc. 400-83.2016 - fl. 378), razão pela qual majoro em 1/6 a pena, totalizando 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e o pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou diminuição da pena, torno definitivas as reprimendas fixadas nas etapas anteriores.

O dia-multa é fixado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado), à míngua de provas sobre as condições econômicas dos réus.

Para início de cumprimento de pena, norteadas pelos critérios previstos no artigo 33, do Código Penal, em razão do quantum da pena e em virtude da reincidência, fixo o regime inicial fechado para o réu Carlos Eduardo, razão pela qual também não faz jus aos benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Para os réus Felipe Daniel e Cesar, vez que primário e sem antecedentes, fixo regime inicial aberto. Em razão do quantum da pena fixada, verifica-se que estão presentes os requisitos contidos nos incisos I (pena não superior a quatro anos e crime cometido sem violência ou grave ameaça), II (réu não reincidente em crime doloso) e III (circunstâncias judiciais que não são desfavoráveis) do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual tem os condenados direito à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), a serem definidas em sede de execução.

Observo ainda que deixo de suspender a execução da pena privativa de liberdade (art. 77, incisos I, II e III, do Código Penal), por se mostrar mais indicada às finalidades da pena, quais sejam: a prevenção geral e especial e retribuição, a substituição adotada no parágrafo anterior.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER os réus CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, conhecido por "Neguito", qualificado à fl. 113, CÉSAR DA SILVA DE SOUZA, conhecido por "Garoto", qualificado à fl. 03, e FELIPE DANIEL GOMES, qualificado à fl. 35, do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, com a espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e CONDENAR:

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, conhecido por "Neguito", qualificado a fls. 113, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário legal (isto é, 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado), por infração ao disposto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

CÉSAR DA SILVA DE SOUZA, conhecido por "Garoto", qualificado a fls. 03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário legal (isto é, 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado), por infração ao disposto no

artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

FELIPE DANIEL GOMES, qualificado a fls. 35, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário legal (isto é, 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado), por infração ao disposto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Autorizo, desde já, a destruição de entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames e decreto a perda em favor da União, dos objetos e valores apreendidos, que serão revertidos diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63 e § 1º da Lei nº 11.343/06.

"Status Libertatis": Considerando os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e o fato de os réus terem sido postos em liberdade em sede de "Habeas Corpus", concedo aos acusados o direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiverem custodiados, já que não sobreveio qualquer alteração fático-jurídica apta a caracterizar a contemporaneidade do "periculum libertatis" e, conseqüentemente, ausentes os requisitos para a decretação de sua custódia cautelar.

Transitada em julgado:

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe.

Expeça-se certidão de honorários em favor dos Defensores Dativos, consoante termos e valores do Convênio OAB/Defensoria Pública.

Condene os réus ao pagamento das custas e despesas processuais (artigo 804 do CPP), suspensas as exigibilidades, porquanto lhes concedo o benefício da justiça gratuita.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Guararapes, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA